

1502561-20.2020.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: EDUARDO CALVERT
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HUGO COTRIN ROCHALO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CALVERT

Vistos.

Hugo Cotrin Rochalo, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
3ª Vara Criminal
Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1502561-20.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502561-20.2020.8.26.0616
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HUGO COTRIN ROCHALO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CALVERT

Vistos.

Hugo Cotrin Rochalo, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15.12.2020, por volta das 17hs30min, na Rua Professor Lucinda Bastos, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas no auto de exibição e apreensão de folhas 18-19, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (folha 102), o réu apresentou defesa preliminar (folhas 134-135). Recebida a denúncia (folhas 145-146), o réu deixou de ser citado (folhas 165 e 186).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, passando-se, por fim, ao interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da exordial, com consideração negativa da quantidade e da qualidade das drogas na primeira fase da dosimetria, fixando-se o regime fechado para início do cumprimento de pena. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, pela insuficiência do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, com fixação do regime aberto para início do cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, anoto que uma questão de ordem processual deve ser enfrentada: conforme se atesta das certidões de folhas 165 e 186, bem como da decisão de folhas 200-201, o réu não foi localizado para citação.

O procedimento especial estatuído pela Lei 11.343/06 prevê a notificação do denunciado para oferecer defesa prévia (artigo 55) e, somente após o efetivo recebimento da denúncia, a sua citação (artigo 56).

A ausência de citação acarreta óbvia nulidade processual. No entanto, na hipótese específica do procedimento especial ora tratado, entendo que a notificação prevista no artigo 55 da Lei 11.343/06 cumpre integralmente com a finalidade da citação, de forma que inexiste prejuízo à Defesa, que inclusive apresentou resposta escrita nos autos.

Inexiste, portanto, nulidade, uma vez que inexistiu prejuízo ao exercício da defesa, inclusive considerando-se que o réu compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. CONHECIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. II - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM INOCORRENTE.

NATUREZA DA DROGA. PRIMERA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO DIVERSA.

1. A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório.

2. Segundo se extrai da operação de individualização da pena, a natureza e quantidade de drogas serviu para a fixação da pena base, enquanto que a negativa do tráfico privilegiado se baseou na comprovação de que um os réus se dedicavam à atividade criminosa, o que é matéria a ser enfrentada somente em sede de cognição plena, independentemente de a reincidência recair apenas quanto a um dos apenados.

Agravo desprovido.

(AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PACIENTE PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO. RITO PROCESSUAL ESPECIAL DA LEI ANTIDROGAS, QUE NÃO PREVÊ A CITAÇÃO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DA PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPRE EVENTUAL NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INDICAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.
 2. A notificação do acusado para oferecer defesa prévia atende aos ditames da Lei de Drogas, que em seu art. 55, não prevê a necessidade de citação pessoal para apresentar resposta à acusação. A citação se dará após o recebimento da denúncia, para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 56 do referido diploma legal.
 3. No caso, além de ter sido apresentada defesa preliminar em favor da acusada, ela esteve presente aos atos processuais, acompanhada de defensor, inexistindo mácula que justifique a anulação da ação penal.
 4. Na esfera penal, nenhum ato será declarado nulo, salvo se dele adveio efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563, do Código de Processo Penal).
 5. Writ não conhecido.
- (HC 236.398/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 05/09/2016)

E, no mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade do processo, em razão de ausência de citação. Inocorrência. Réu que mudou de endereço sem comunicar o juízo, tendo, porém, plena ciência da imputação que lhe foi dirigida, por meio da notificação pessoal para a apresentação da resposta escrita à acusação. Finalidade da citação alcançada. Precedentes do STJ. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada. No mérito, confissão extrajudicial corroborada pelas demais provas, sob o crivo do contraditório. Absolvição inviável. Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Inadmissibilidade. Réu que foi surpreendido por policiais militares em plena atividade criminosa, e que foi delatado, nas duas fases do processo, pelo usuário a quem vendia droga no momento da prisão. Penas bem dosadas, em conformidade com a gravidade do caso concreto, que, por si só, todavia, não autoriza a imposição do regime inicial fechado, que fica alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001567-81.2017.8.26.0548; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Dessa forma, inexistente irregularidade a ser sanada.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (folhas 1-2), pelo boletim de ocorrência (folhas 13-17), pelo auto de exibição e apreensão (folhas 18-19), pelas fotografias de folhas 20-26, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (folhas 8-12) e pelos laudos dos exames químicos toxicológicos (folhas 122-129), com resultado positivo para Cannabis sativa L (ou "maconha"), "cocaína", "cocaína na forma de crack" e anfetamina.

A quantidade de drogas encontrada, a forma de armazenamento e as circunstâncias do

caso concreto, indicam que se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros, tipificando o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito. Disse que foi ao local para adquirir drogas e que foi abordado pelos policiais no momento em que usava drogas e estava com um cachimbo na mão; disse que os policiais exigiram que ele apontasse quem era o traficante e que o prenderam em razão de ele não haver acusado o traficante. Disse que os policiais sabiam que ele não estava vendendo drogas. Disse que os valores apreendidos não lhe pertenciam, assim como as drogas encontradas numa sacola. Disse que em razão do nervosismo deu o número errado de seu endereço, razão pela qual não foi encontrado para citação.

Não obstante a negativa do réu, os demais elementos dos autos são bastante claros acerca da autoria.

Com efeito, as testemunhas confirmaram a apreensão das drogas na posse do réu e as circunstâncias de sua prisão em flagrante.

A testemunha Bruno Souza Santos, ouvido em juízo, afirmou que é guarda municipal e que na data dos fatos realizava patrulhamento preventivo no local dos fatos, conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando avistaram o réu sozinho, o qual se mostrou nervoso ao avistar a viatura ("parecia que ele queria fugir, mas como a viatura estava próxima ele ficou paralisado"), motivando a abordagem. Com o réu foram encontrados valores em dinheiro trocado e, ao seu lado, havia uma sacola com as drogas apreendidas (não se recorda a quantidade, mas eram de diversas qualidades). O réu permaneceu calado durante a abordagem.

Adriano Lima Pinheiro, ouvido em juízo, confirmou os fatos narrados por Bruno Souza Santos. Disse que visualizaram o réu em atitude suspeita, o qual demonstrou nervosismo quando da aproximação dos policiais. Com o réu foram apreendidos valores em dinheiro e as drogas foram encontradas em uma sacola ao lado do réu (à distância de um braço do réu). Havia maconha e crack na sacola, mas não se lembra exatamente. Disse que o réu estava com as roupas sujas.

Os depoimentos de policiais militares ou civis, ou dos guardas civis, na condição de testemunhas, devem ser considerados idôneos. Não se concebe que os agentes, sem razão aparente, pretendessem incriminar inocentes desconhecidos, de forma tão abjeta. A ilação dos agentes foi corroborada, por sinal, pela eloquente apreensão das porções de entorpecente.

Ao contrário: são testemunhas que depõem compromissadas, com presunção de veracidade por serem funcionários públicos, narrando sobre atos que, de ofício, foram praticados no exercício de suas funções.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 73.518, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 26.3.1996)

“PROVA - Depoimento de policial - Valor: Não demonstrando a defesa, como lhe incumbe à luz da regra do artigo 156 do CPP, os motivos que teria o policial para, ciente da inocência do acusado, imputar-lhe falsamente a prática de crime, seu depoimento, firme e coerente naquilo que é essencial, deve ser prestigiado em detrimento da palavra do réu, principalmente quando este apresentar personalidade voltada para a prática de ilícitos penais”. (Tribunal de Alçada Criminal, apelação 1.442.515/4, relator Desembargador Xavier de Souza, julgada em 29.6.2004)

Impossível, portanto, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, sob a argumentação de que as drogas não se destinavam à entrega a terceiros, mas sim ao consumo próprio, uma vez que não está em conformidade com os elementos probatórios colhidos dos autos.

As circunstâncias do caso concreto impedem que seja acolhida a tese da desclassificação. A quantidade de drogas encontrada não se coaduna com o uso por apenas uma pessoa em curto espaço de tempo. O réu também não foi surpreendido com petrechos para o uso de drogas, tudo levando a conclusão de que estava efetivamente vendendo drogas.

Desta feita, a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é de rigor.

Será aplicável, no entanto, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é tecnicamente primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas.

Não há qualquer elemento de prova que indique que, à época dos fatos tratados no presente processo, o réu dedicava-se a atividades criminosas.

Ademais, a quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias do caso concreto não permitem enquadrar o réu como grande traficante ou como detentor de uma rede organizada de venda de drogas, assemelhando-se ao pequeno traficante, premido pelo vício em entorpecentes ou pelas circunstâncias sociais, a quem a lei pretendeu beneficiar pela causa de diminuição de pena em relevo.

Passo à dosimetria da pena, o que faço nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e dando preponderância à natureza e à quantidade da substância, à personalidade e à conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, pondero que a qualidade da droga apreendida deve ser considerada para o recrudescimento da pena-base.

Com efeito, o artigo 42 da Lei 11.343/06 determina que seja considerada a qualidade da droga para fins de estabelecimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Esta determinação legal, aliada à grande elasticidade do preceito secundário do tipo criminoso do artigo 33, caput, desta lei, indica que o juiz deverá aplicar penas diferentes para os diferentes tipos de substâncias entorpecentes, de acordo com a lesividade da droga.

No sentido de apenarem-se de forma diferenciada os traficantes de acordo com a quantidade e a qualidade da droga comercializada, dando efetividade ao princípio da individualização da pena, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A despeito do sustentado pela defesa, o magistrado de primeiro grau fundamentou exaustivamente a fixação da pena base do réu acima do mínimo legal, pautando-se no art. 42 da Lei 11.343/06, observando a quantidade e natureza da droga, bem como a conduta social do acusado. Tais circunstâncias extrapolam o já previsto pelo tipo e

devem ser consideradas pelo magistrado quando da fixação das penas, como disposto no supramencionado artigo, pois no presente caso extrapolam o já previsto pelo tipo.

Assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo.

Repise-se, o art. 42 da Lei 11.343/06 é expresso ao determinar que a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base". (apelação 0001695-14.2013.8.26.0396, relatada pelo Desembargador Edison Brandão, julgada em 9.9.2014, extraído do voto relator)

No caso dos autos, com o réu foram apreendidas porções de "crack", droga que pode, sem qualquer receio de erro, ser apontada como a mais lesiva entre todas aquelas que são comumente comercializadas pelos traficantes, a qual determina grave dependência física e psicológica, afeta de forma agressiva o sistema nervoso central e acarreta em graves sequelas pessoais aos usuários, determinado comportamentos agressivos e antissociais por parte do usuário, de forma a causar danos pessoais, sociais e familiares graves e perenes.

Impossível apenar da mesma forma o agente que vende "crack" e aquele que vende outras drogas de potencial lesivo reconhecidamente menor.

Desta forma, em atenção à qualidade da droga comercializada pelo réu, recrudesço sua pena-base em 2 (dois) anos, a qual fixo em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de 1/2 (metade), passando a pena a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

A diminuição da pena abaixo do máximo legal se justifica pela qualidade das drogas apreendidas em posse do réu e sua diversidade, demonstrando que ele realizava o tráfico de forma organizada, e pelas circunstâncias do caso concreto, que apontam a necessidade de maior reprimenda à sua conduta.

À mingua de outras causas modificativas, torno definitiva as penas fixadas acima.

A pena pecuniária será calculada no patamar mínimo legal, ante a ausência de dados sobre a capacidade financeira do réu.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser cumprida em regime inicial aberto, tendo em vista a quantidade da pena imposta e a sua primariedade, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a imposição de regime inicial fechado prevista no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reclusão, e limitação de fim de semana, com indicação de tratamento de conscientização e desintoxicação para dependentes de drogas, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 47 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, bem como os motivos e as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente para o cumprimento das finalidades da persecução criminal, ressaltando-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da substituição, quando presentes os requisitos legais, não obstante a vedação do artigo 44 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar Hugo Cotrin Rochalo, qualificado nos autos, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reclusão, e limitação de fim de semana, com indicação de tratamento de conscientização e desintoxicação para dependentes de drogas, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 47 da Lei 11.343/06.

O réu poderá interpor recurso de apelação em liberdade, tendo em vista a aplicação de penas não privativas de liberdade. Imponho ao réu, no entanto, as medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal, conforme abaixo delineado:

Comparecimento periódico ao juízo criminal, a cada bimestre, para informar e justificar suas atividades;
Proibição de ausentar-se da comarca de sua residência ou de mudar de endereço sem a prévia autorização deste juízo;
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e
Obrigação de comparecimento perante a autoridade judiciária todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e julgamento.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03, condeno, ainda, o réu, ao pagamento das custas judiciais, no valor de 100 (cem) Ufesps. Observem-se, no entanto, as disposições do artigo 12 da Lei 1.060/50.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Mogi das Cruzes, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA